

0001643-31.2012.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Maus Tratos

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Neste sentido, inclusive, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se posicionou em casos análogos:

"Tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001643-31.2012.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001643-31.2012.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Maus Tratos

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 10/2012 - Delegacia de Polícia de Ubarana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wynitu Kelfs Maia e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

DELFINA MARIA ARROYO DE OLIVEIRA MAIA e WYNITU KELFS MAIA, qualificados no auto do processo em epígrafe, foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso II, § 2º, da Lei nº 9.455/97, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) e WYNITU KELFS MAIA, como incurso no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), porque, durante o ano de 2011, no Centro de Recuperação Renova em Cristo, localizada na Rua Manoel Teodoro do Prado, ao lado da Rodovia, centro, na cidade de Ubarana/SP, Rogério, este até o momento não identificado e WYNITU KELFS MAIA, qualificado às fls. 103, previamente ajustados e com unidade de desígnios, submeteram Lucas Lopes de Menezes e Silvio Gouvea dos Santos Neves, sob seus poderes e autoridades, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal

ou medida de caráter preventivo.

Consta que, nas mesmas circunstâncias, WYNITU KELFS MAIA e DELFINA MARIA ARROYO DE OLIVEIRA MAIA, qualificada às fls. 67, se omitiram em face das condutas praticadas pelo monitor Rogério, quando tinha o dever de evitá-las e apurá-las.

Segundo apurado, no ano de 2011, por pelo menos 4 (quatro) meses, as vítimas Lucas Lopes de Menezes e Silvio Gouvea dos Santos Neves foram submetidos a castigo, consistente em serem aprisionados em uma cela, denominada "Pote", local sem banheiro ou água encanada, onde permaneciam encarcerados. Apurou-se, ainda, que durante o período em que as vítimas estiveram na clínica, sofreram agressões físicas e psicológicas, onde eram espancados, sofrendo chutes na cabeça, tapas e esganadura, bem como eram trancados em quartos, sem alimentação e água, sendo que muitas faziam necessidades fisiológicas nas roupas. Também eram submetidos a medicações de intenso efeito, ficando totalmente dopados.

Além das vítimas serem submetidas a agressões físicas e de ordem psicológicas, eram utilizados medicamentos que lhes causavam supressões da capacidade física, motoras e psíquicas dos internos; bem como eram submetidos a cárceres privados e privações das condições basilares de conforto e higiene, já que eram trancados em um quarto denominado "Pote" sem ventilação, sem banheiro, sendo utilizados baldes para as necessidades fisiológicas que tinham por motivo castigo pessoal.

A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2015 (fl. 166).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 216/226).

Realizada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, as vítimas foram ouvidas, bem como foi inquirida as testemunhas arroladas. Após, os réus foram interrogados.

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade em relação à ré DELFINA pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e a parcial procedência da denúncia para condenação do réu WYNITU.

A Defesa dos réus requereu a improcedência da ação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. Os acusados foram representados por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, é o caso de reconhecimento da chamada de prescrição virtual em relação à ré DELFINA MARIA ARROYO DE OLIVEIRA MAIA pelo suposto delito previsto no artigo 1º, inciso II, § 2º, da Lei nº 9.455/97.

Isto porque, sabe-se que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a chamada prescrição antecipada ou virtual, que se caracteriza com a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta para tanto a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, "a pena que seria, em tese, cabível ao acusado" (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código Penal Comentado, 4ª ed., RT, 2003, p. 380).

Considerando-se que a ré é primária e não registra sequer maus antecedentes, bem assim a ausência, na espécie, de outras circunstâncias ou causas modificadoras, bem como que o crime se configuraria na hipótese do §2º do artigo 1º da Lei nº 9.455/97, a pena, na hipótese de eventual condenação, seria fixada no mínimo legal, de 1 (um) ano de detenção, com continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal e aumento de 1/6 (um sexto), o que implica, consoante o Art. 109, V, do Código Penal, no prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Ora, nota-se que a denúncia foi recebida em 14/08/2015 (fls. 166).

E, pela pena que virtualmente seria aplicada à ré, já que não há mesmo, numa análise pragmática, a menor possibilidade de ser ela apenado com mais do que 2 (dois) anos de detenção, acaso venha a ser condenada, estamos diante da hipótese da prescrição virtual.

Impõe-se, em semelhante tessitura, a declaração antecipada da prescrição pela pena

em concreto, evitando-se, com isso, a dispendiosa e desnecessária continuidade de movimentação da máquina judiciária em relação a um processo cuja eventual condenação dela resultante estará, ao final, inexoravelmente atingida por tal fenômeno.

Portanto, de rigor a extinção da punibilidade da ré DELFINA MARIA.

No mais e no mérito, a pretensão penal punitiva em relação ao réu WYNITU KELFS MAIA é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do delito está comprovada pelo inquérito policial (fl. 05), contrato particular de tratamento terapêutico para dependentes químicos e alcoólatras (fls. 12/16), denúncia registrada (fls. 28/29; 46/47), termos de declarações (fls. 31/33; 52/53; 76; 122/123; 158/159), relatório final (fls. 128/132), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa. Vejamos.

Lucas Lopes de Menezes (vítima) disse que tinha 17 anos. Foi uma das primeiras clínicas que ficou. Caso falasse que queria ir embora no momento da visita, ela era cortada e falavam que ele estava manipulando para usar droga. Era feito um "danoninho" com remédios amassados, com isso, a pessoa dormia o dia todo e fazia necessidades na roupa. Mandaram esfregar o chão com escova de dente, então tentou fugir, mas o pegaram, amarraram, e colocaram quatro cobertas sobre ele, mesmo estando calor. Conversou com uma mulher do conselho tutelar, falou tudo o que acontecia e depois de um tempo a clínica fechou. Wynitu e Delfina batiam na sua cara enquanto estava amarrado. Conhece várias pessoas que passaram pela mesma situação. Wynitu era uma das piores pessoas que tinha no local. Whynitu mandava lavar todas as panelas e as sujavam novamente para serem lavadas de novo. Quando o ouviam falar que iria voltar a usar drogas, mandavam cavar buraco. Ficava amarrado de um dia para o outro. Havia agressão física, como tapa na cara, banho de água gelada em dias frios e era colocado cobertas sobre eles em dias quentes. O nome da clínica era Centro de Recuperação Renovo em Cristo.

Silvio Gouvea dos Santos Neves (vítima) declarou que, em 03 de novembro de 2010, ficou internado na clínica de Delfina e Wynitu. A internação ocorreu até 2012, quando fugiu de lá. Nessa data de 03 de novembro de 2010, tinha recaído no álcool. Em 2011, estava trancado na clínica. A internação era de 90 dias. Não sofreu agressão direta por parte de Delfina e Wynitu diretamente. Porém, eles mandavam os funcionários o agredirem. Eram trancados em quartos fechados, de cueca. Passou 20 dias trancado em um quarto, em um calor infernal, com uma garrafa de água. Para urinar, tinha que urinar em uma garrafa. Só saíam duas vezes por dia, para almoçar e fumar. Ficavam confinados no local. No local, tinha uma porta de ferro fechada. Para respirar, tinham que colocar o nariz debaixo da porta. O quarto não tinha janela, apenas uma porta lacrada. O depoente é portador de HIV e disse que não poderia ficar com 8 pessoas trancadas. Então, foi aberta uma janelinha para o depoente. Só podiam urinar na garrafa. Para outras necessidades, batia na porta e pedia para sair. Os funcionários o trancaram a mando da dona da clínica e de Wynitu. Sofreu agressão física, com enforcamento no pescoço e "sossega leão", quando os outros fugiram. As agressões foram praticadas a mando de Wynitu.

Atualmente, toma diazepam e coquetel. Tinha uma farmácia no local e tinha uma enfermeira. A pessoa tomava remédios segundo a receita. Porém, quando aprontavam algo que não era do agrado de Wynitu, ele diluía remédio (diazepam, rivotril, etc.) na água e dava para a pessoa beber. Quando a família ia fazer o resgate, eles deixavam o remédio para a família desmaiar a pessoa para a clínica buscar. Ficou dopado várias vezes, três dias de cama dormindo. Eram dopados sem prescrição médica. "Pote" era um quarto com uma porta de ferro, um quarto pequeno onde ficavam 8 pessoas de cueca, por 20 dias. Urinavam na garrafinha e a urina ficava no local. Era uma espécie de "solitária". Ficou internado na clínica porque é dependente de álcool e teve uma recaída. Não fazia uso de drogas. Quando foi para clínica, estava morando na sua casa em Penápolis. Teve uma recaída e o amigo ligou para a irmã. A clínica custava 1.300 reais. Foi arrancado dentro de sua casa e levado para a clínica. Estava em uso de álcool na época. Quando foi para a clínica, não passou por qualquer avaliação médica. Não o levaram para fazer o exame de HIV, nem

verificaram para ver sua saúde. Não tinha prescrição médica da clínica. Foi para a clínica sem remédios, apenas com a roupa do corpo. Não passaram ao depoente qual era o tratamento médico. Apenas tomaram o remédio que passavam para o depoente e ficava dopado. Não sabiam os remédios que recebia. A enfermeira falava que era um calmante. Eles davam remédio da forma que queriam, misturando vários remédios. Na clínica, tinha um psicólogo, chamado Tadeu de Paula, que é cúmplice de tudo que aconteceu na clínica. Ele ligava para a família, que dizia que está tudo bem. O tratamento eram 9 meses. Alimentava-se muito mal. Vez ou outra, tinha um churrasco, quando a clínica ganhava doação. Depois de um ano, recebeu visitas da irmã e da mãe. Não podia falar o que acontecia dentro da clínica sobre como todos sofriam maus tratos dentro da clínica. Tinha que trabalhar de 6h da manhã até 19h da noite, porque, se não o fizesse, iria ser agredido. Nunca deu remédio para ninguém na clínica. Quem dava os remédios era a enfermeira. Foi colocado como monitor para ajudar a clínica. Estudou o livro de narcóticos anônimos e ajudou na clínica, de uma forma justa. Quando saiu da clínica, foi para a Osvaldo Cruz. Não voltou a beber. Os remédios que toma são clonazepan e diazepam, pois é alcoólatra, pois o alcoolismo é doença. Também toma remédio para HIV. Faz tratamento com psiquiatra. Só toma remédios à noite. Delfina Maria é mãe dos donos da clínica. Ela entrou no negócio enquanto estava internado na clínica. Chegou a falar para ela que queria sair dali e ela debochou. Ela sabia de tudo que acontecia e nunca fez nada. Ela diretamente não a agredia, mas mandava os outros. Wynirtu é o dono da clínica. Wynitu tinha conhecimento. Ele sabia o que acontecia e mandava os empregadores fazerem, para os internos não ficarem com raiva dele. Presenciou Wynitu determinando agressões. Ele ficava trás da parede, dando ordens. Rogério era um dos funcionários. Algumas pessoas faziam necessidade nas roupas, porque estava dopados de remédio e ficavam 3 dias dormindo.

Alessandro T. H. Andreotti (testemunha de acusação) na época dos fatos era delegado na cidade de Ubarana. Havia uma clínica de recuperação de adictos e etílicos. Tiveram informações de maus-tratos. Em busca e apreensão, constatarem um verdadeiro campo de concentração. Maus-tratos generalizados, todos os internos foram unânimes em dizer que qualquer desagrado que cometessem, eram obrigados a lavar banheiro com escova de dente, agredidos por três ou quatro integrantes, obrigados a tirar muda de tiririca com as mãos, no sol quente. Todos disseram que eram colocados em um lugar chamado "Pote", onde havia uma grade, e ficavam com apenas uma caneca d'água e um balde de 20 litros para fazer necessidades, ficando lá por três a quatro dias. Achou uma grande quantidade de medicamentos sem receita. Eram amarrados nas camas e agredidos. Todos foram unânimes em dizer que quando agiam de forma indisciplinada aos olhos dos donos, eram medicados com uma mistura chamada de "shake", feito com medicamentos que os apagavam por três a quatro dias. Um dos membros da clínica fugiu e se escondeu na delegacia, então vieram quatro pessoas, invadiram a delegacia e passaram por eles com faixa de judô para amarrar o indivíduo. Um dos proprietários, chamado Wynitu abriu uma clínica nestes mesmos moldes em Campos do Jordão e um dos pacientes faleceu. Os proprietários eram Wynitu, o irmão e a mãe. Se chamavam de terapeutas e diziam terem se graduado pela internet. Prestavam serviço na base da agressão, de trabalho forçado, administração de drogas e castigo severo. O nome do local era Clínica de Recuperação Renovo em Cristo. Eram três proprietários e todos davam ordens. Eram vários terapeutas. As famílias deixavam em troca da aposentadoria do pessoal. O alojamento fica dentro de uma grade, como se fosse um canil. Não presenciou nenhuma agressão.

Lislaine Martins Lopes (testemunha de acusação) disse, em juízo, ser mãe de Lucas Lopes de Menezes. Procurou uma clínica quando descobriu que seu filho estava usando drogas e esta foi a mais barata que encontrou. Recebia ligações de pessoas falando sobre o local, mas não deu atenção. A dona da clínica falava para não dar atenção, pois eles manipulavam. Nas visitas não conseguia conversar muito, pois os terapeutas ficam sempre próximos. O conselho tutelar ligou falando para observar a clínica e disseram estar recebendo denúncia. Presenciou uma agressão em seu filho. Foi conversar com o psicólogo e seu filho estava em uma sala separada, quando ouviu um tapa, então perguntou o que aconteceu, mas negaram ter batido no seu filho. No momento não deixaram conversar com ele. Depois o conselho tutelar ligou e pediu

para ficar quieta, pois estava em observação. Seu filho contava algumas coisas, dizendo que estava sofrendo maus tratos, mas não conseguiam conversar muito. Seu filho comentou que era amarrado, e colocado em cobertas, mesmo estando muito calor. Não deixavam entrar no local onde ficava a cama dele ou o banheiro que utilizava. Uma das vezes viu um calombo no seu filho, mas ele não falava, por conta dos terapeutas sempre próximos. Depois, ficou sabendo por seu filho que quem deu o tapa foi Delfina. No dia do tapa, tinha ido no fórum e seu filho havia falado que iria contar tudo para o juiz, mas não houve audiência. Ele correu do carro e o pessoal foi atrás dele. Não lembra o nome da conselheira que ligou falando que ele estava sofrendo maus-tratos.

Lucimara Aparecida Barbosa (testemunha de acusação) disse, em juízo, que era conselheira tutelar. Receberam denúncia e foram averiguar. Os adolecentes não relataram nada sobre maus-tratos, mesmo quando questionados. Não se recorda o que colocou no relatório. Recebeu denúncia anônima. Foi até o local, tiveram acesso livre e conversaram com o adolescente, o qual não confirmou sobre os maus-tratos. Tiveram denúncia sobre o poço. No local, não presenciou situação de maus-tratos. Chegavam de surpresa. Recebeu denúncia e continuaram a ir no local. Não se recorda quem foi até o local com ela. O ambiente não era adequado para os jovens. A higiene da cozinha e dos quartos era precária. Não viu nenhum quarto sem janela. Visitou o local mais de duas vezes. Não havia nenhum sinal que não estavam sendo bem tratados.

Endry Carobene Franceschi (testemunha de acusação) disse que conhecia a clínica por ser coordenador da vigilância sanitária. Fazia visitas na tentativa de regulamentar a clínica. Eles entraram com a documentação para regulamentar. Notou irregularidades em termo de estrutura, como problemas estruturais. Não havia a equipe profissional pedida na portaria. Havia problemas em termos de pintura e divisão de alguns quartos. Não verificou maus-tratos. Não tem conhecimento do poço e não recebeu relato. Em uma das visitas foi o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Regional de Saúde de Rio Preto e o Conselho Tutelar. A polícia não foi. Foi em todos os cômodos. Não existia cômodos fechados ou sem iluminação. Foi em torno de sete vezes. Não houve pacientes em situação de riscos ou com hematomas.

Delfina Maria Arroyo de Oliveira Maia (ré) disse, em juízo, que a acusação não é verdadeira. Quando esses meninos saem da clínica, fazem acusações por não quererem voltar para o tratamento. A alimentação era ótima. Só tomam medicação mediante prescrição médica. O quarto não existe, é inventado. Rogério fez tratamento na clínica e, quando fazem tratamento, ajudam no local. Inventam por quererem sair da clínica e não voltar. Fechou a clínica. A clínica funcionou por dois anos. Teve todos os alvarás regularizados. Era uma clínica aberta, quando foi fazer uma clínica de contenção, que a pessoa não pode ir embora sem a família querer, achou melhor fechar. Trabalhou com internos que não podiam ir embora se quisessem. Adotava a medida de conversa para não saírem. Os que fugiam não tinham punições. Não havia punição por descumprimento de regra dentro da clínica. Um dos internos contou que onde já havia ficado internado tinha um pote, por isso todos contavam a mesma versão. Se quisessem fugir somente conversavam, e ficavam no escritório até a família chegar. Não saíam na força, somente fugiam.

Wynitu Kelfs Maia (réu) - revelia decretada.

Finda a instrução processual, as provas são suficientes para fundamentar a parcial condenação.

O acusado Wynitu, na fase extrajudicial, exerceu o direito ao silêncio (fls. 122). Em juízo, houve decretação da revelia.

Contudo, a prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Lucas, em juízo, foi clara ao afirmar que permaneceu internado na clínica, que era submetido a ingerir remédios amassados (denominado "danoninho") que faziam o dormir o dia todo, inclusive urinar e defecar nas próprias roupas. Relatou, também, que o réu e os funcionários mandavam esfregar o chão com escova de dente, que ficava amarrado de um dia para o outro, que batiam em seu rosto enquanto permanecia amarrado, que sofria agressão física como tapa na cara, banho de água gelada em dias frios e era colocado cobertas sobre ele em dias quentes, que o réu

mandava a vítima lavar todas as panelas e as sujavam novamente para serem lavadas de novo. Descreveu que, em uma tentativa de fuga da clínica, foi capturado pelos funcionários, amarrado e colocado sobre ele quatro cobertas, mesmo estando calor. No mesmo sentido, a vítima Silvío, que também foi paciente da clínica, afirmou que o réu determinava as agressões contra os internos e que ficassem confinados em um local sem condições de higiene, denominado "Pote", uma espécie de "solitária". Relatou que não sofreu agressão direta por parte de Delfina e Wynitu, mas que eles mandavam os funcionários o agredirem, tendo, inclusive, presenciado o réu atrás de uma parede determinando as agressões. Descreveu que os pacientes eram trancados em quartos fechados sem janela e com uma porta lacrada, de cueca, em "um calor infernal", com apenas uma garrafa de água; que para urinar faziam uso de uma garrafa; que apenas saíam do quarto duas vezes por dia para almoçar e fumar; que no local tinha uma porta de ferro fechada; que para respirar tinham que colocar o nariz debaixo da porta. Afirmou que os funcionários o trancaram, por 20 dias, a mando da dona da clínica e do réu. Relatou, também, que sofreu agressão física, com enforcamento no pescoço e "sossega leão", além de ter ficado sob efeito de remédios por várias vezes, permanecendo três dias dormindo, sem prescrição médica. Disse que tinha que trabalhar das 6 horas da manhã até às 19 horas, porque, se não o fizesse, iria ser agredido/castigado. Relatou, ainda, que algumas pessoas urinavam e defecavam nas roupas, em razão do uso de medicamentos fornecidos pelos funcionários da clínica.

Assim, importante observar que as palavras das vítimas estão seguras, fortes, coerentes e harmônicas, emprestando-lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusão única de sua aceitação, especialmente porque corroborada por depoimentos testemunhais firmes, que evidenciam que as vítimas foram submetidas a um grave quadro de agressões físicas e confinamentos com punições.

A testemunha Lislaine, mãe da vítima Lucas, disse, em juízo que ouviu denúncias de maus tratos e, em certa ocasião, ao estar na clínica, ouviu um tapa sendo desferido, porém no momento não deixaram conversar com Lucas. Posteriormente, ouviu do filho que o tapa fora desferido por Delfina. Afirmou, também, que, nos dias de visitas, Lucas contava apenas algumas coisas, dizendo que estava sofrendo maus tratos, mas não conseguiam conversar muito, por conta dos terapeutas sempre estarem próximos. Relatou que seu filho havia comentado que era amarrado e colocado em cobertas, mesmo estando muito calor, e que não deixavam entrar no local onde ficava a cama de Lucas ou o banheiro que utilizava. Uma das vezes viu um calombo no seu filho, mas ele não falava a causa, em razão da presença dos terapeutas nos momentos de visitas.

No mesmo sentido, o delegado Alessandro disse, em juízo, que foi ao local e presenciou "um verdadeiro campo de concentração" e que todos os ouvidos, na ocasião, disseram que eram agredidos por proprietários e por funcionários, além de serem colocados no "Pote", quarto sem janelas e com condições precárias de higiene e condições dignas de tratamento. Afirmou, ainda, que encontrou grande quantidade de medicamentos sem receitas, sendo que todos foram unânimes em afirmar que eram medicados e ficavam dopados por 3 a 4 dias. Em uma ocasião, relatou que um interno fugiu da clínica e se escondeu no interior, sem perceber que era uma delegacia, momento em que os funcionários entraram com uma faixa, para amarrar o interno. A testemunha disse que o réu e Delfina determinavam como seriam os castigos e que o alojamento ficava dentro de uma grade como se fosse um canil.

A testemunha Lucimara, conselheira tutelar na época dos fatos, disse que recebeu denúncia para averiguar o local, constatando que a higiene era precária. Já Endry, coordenador da vigilância, viu que havia problemas no prédio e a equipe não era preparada, embora não tenha tomado conhecimento dos maus tratos.

Portanto, o conjunto probatório mostra que ocorriam agressões físicas e confinamentos com punições por parte do réu Wynitu, mediante ordens e determinações a serem cumpridas e executadas pelos funcionários da clínica. Assim, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o delito previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, que lhe foi imputado na denúncia.

O crime de tortura restou configurado, na medida que as vítimas foram submetidas a grave sofrimento físico e mental, com o fim de intimidá-las e castigá-las durante o

tratamento clínico, além de submeterem-nas a confinamentos com punições, como claramente comprovado pelos depoimentos colhidos durante a instrução. Além das definições previstas no artigo 1º da Lei nº 9455/97, de acordo com a Convenção Contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, ratificada pelo Brasil em 1991, "'tortura' designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram".

Não à toa que a prática de tortura é considerada crime equiparado aos crimes hediondos pela legislação brasileira e proibida pela Declaração dos Direitos Humanos (artigo V), Convenção Americana de Direitos Humanos (Art. 5º, 2) e pela Constituição Federal (Art. 5º, III).

Diversamente, não há se falar em desclassificação para o crime de maus tratos, posto que de acordo com Cleber Masson, este "tipo penal reclama uma vinculação especial entre o autor e a vítima dos maus-tratos (crime próprio). O ofendido deve estar sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, mas pouco importa o grau de instrução ou a classe social do responsável pela conduta criminosa".

Ainda, não é caso de atipicidade da conduta por falta de materialidade. Isso porque, embora as lesões corporais da vítima não tenham deixado vestígios, houve, no caso, além da violência física, tortura psicológica das vítimas, sendo toda a ação delituosa comprovada pela prova oral e ante o uso de medicamentos até os dias atuais.

E mais, consoante já decidiu o E. TJSP:

"o fato de algumas vítimas não evidenciarem lesões ou demonstrarem a existência de poucos e leves ferimentos não inviabiliza a tipificação do fato como lançada na denúncia, vez que a lei não impõe que as lesões sejam de natureza grave para a caracterização do delito em tela (...) Os adolescentes infratores foram submetidos a agressões físicas, como forma de castigo pela desobediência a uma regra interna, castigo este não previsto em lei (...) Acerca do crime tratado na denúncia, leciona Guilherme de Souza Nucci¹²: "Preferimos, no entanto, um conceito mais abrangente, entendendo por tortura qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão." Assim, a prova colhida demonstrou que a conduta do acusado (...) se amolda ao tipo penal descrito como tortura-castigo, do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997." (TJSP; Apelação 0023447-54.2002.8.26.0161; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017).

De se destacar que "para que haja crime é indispensável a existência de uma conduta, que se pode traduzir tanto em um comportamento positivo (comissivo) quanto negativo (omissivo)".

De acordo com o inciso XLIII, do artigo 5º da Constituição Federal, "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem".

Neste sentido, inclusive, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se posicionou em casos análogos:

"Tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97). Preliminar inconsistente. Nulidade não verificada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Mérito. Provas seguras de autoria e materialidade. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de Policial Civil. Laudo de lesão corporal e fotografias harmoniosas ao narrado pela vítima. Grave quadro de violência física. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regimes adequados. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar." (TJSP; Apelação Criminal 0000465-62.2019.8.26.0157; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/10/2022; Data de Registro: 16/10/2022)

"APELAÇÃO - Tortura e Tortura por omissão - Condenação de ambos os acusados mantida - Recurso interposto pela Defesa - Versões dos acusados isoladas do conjunto probatório - Manifestação expressa da vítima de que sofria os atos de tortura praticados por Richard - Versão do policial militar corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelos laudos periciais - Desclassificação para o artigo 129, §9º do Código Penal que não se mostra possível, já que as condutas praticadas pelo apelante transbordam o bem jurídico protegido pela norma do artigo em comento e amoldam-se, com perfeição, à previsão legal do artigo 1º, §3º da Lei 9.455/97. No mesmo sentido, não se vislumbra possibilidade de desclassificação da conduta para o artigo 136 do Código Penal. Apelante Claudina que, tendo inequívoco dever de proteger e cuidar de seu filho, dele se esquivou - Provas concretas de que a ré tinha ciência - Materialidade do crime de tortura por omissão praticada contra filho menor que decorre da análise do conjunto probatório - Genitora que deve responder por sua omissão penalmente relevante. Dosimetria da pena retificada tão somente para se aplicar a fração mínima prevista em abstrato pela continuidade delitiva, já que não se sabe ao certo a quantidade de vezes que os delitos foram cometidos. Interpretação mais favorável aos apelantes. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1500672-46.2021.8.26.0050; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tortura (artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 9.455/97 c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, e art. 1º, §4º, I da Lei nº 9.455/97). Preliminares. Nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Réu que deu causa à revelia. Quebra da cadeia de custódia não demonstrada. Ilicitude da prova não evidenciada. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 129 do Código Penal - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância das palavras da vítima que relatou em detalhes e com segurança a conduta ilícita de que foi alvo, em todas as oportunidades em que foi ouvida - Dosimetria - Fixação da Pena-base acima do mínimo legal bem fundamentada - Necessidade, porém, de readequação da pena, pois uma das circunstâncias judiciais negativas valoradas se trata de situação inerente ao tipo penal - Incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP - Excessiva majoração - Causa de aumento prevista no artigo 1º, §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97 bem aplicada - Perda do cargo ou função - Efeito automático da condenação conforme o disposto no artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9455/97 - Precedentes - Regime inicial fechado mantido - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0003888-55.2015.8.26.0097; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

Ainda, a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, está devidamente configurada na espécie, uma vez que o réu praticou o delito de tortura em face de, pelo menos, duas vítimas, em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Por outro lado, em relação ao delito previsto no artigo 1º, inciso II, § 2º, da Lei nº 9.455/97, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), descrito, in verbis, "Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.", a denúncia não indica, expressamente e de forma individualizada, a omissão praticada pelo réu Wynitu.

Aliás, a prova oral comprovou que o réu determinava a realização da tortura, o que o enquadraria na prática do delito previsto no §1º. Ora, não há como o acusado ser, ao mesmo tempo, mandante da tortura e omissor em relação a ela. A prática de dois tipos penais distintos exigiria a descrição detalhada e específica das situações em que o réu efetivamente agiu praticando a tortura como mandante (o que está comprovado) e das situações em que o réu apenas se omitiu (o que nem sequer está claramente descrito na denúncia).

Assim, as provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir a responsabilidade penal do réu em relação ao delito previsto no §2º. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor do réu, em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Todavia, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não houve a comprovação dos fatos na fase judicial.

Portanto, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada sobre a autoria da infração penal. A dúvida razoável deve ser resolvida em favor do acusado. O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe quanto ao delito previsto no artigo 1º, inciso II, § 2º, da Lei nº 9.455/97.

Por fim, verifico que o réu Wynitu é primário e não possui maus antecedentes conforme certidão de fls. 1178/1181.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado Wynitu, deve ser considerada muito grave, considerando que as torturas praticadas contra as vítimas demonstraram elevado grau de perversidade e crueldade contra vítimas indefesas. O réu não apresenta maus antecedentes criminais. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos devem ser considerados fúteis, pois as agressões ocorreram de forma gratuita. As circunstâncias são igualmente graves, pois se deram em ambiente de tratamento médico, no qual se espera adequação e profissionalismo. As consequências foram nefastas, considerando que o terror psicológico ao qual submetidas as vítimas refletirá por toda a vida. Diante destas

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/3, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do artigo 61, II, alínea "g" do Código Penal, pois o crime foi cometido com abuso de poder e violação de dever inerente a profissão, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal e devidamente configurada na espécie, como já fundamentado, aumento a pena de 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime semiaberto. Em que pese a primariedade do réu, a gravidade da conduta e as várias circunstâncias negativas do artigo 59, do Código Penal justificam a fixação de regime mais gravoso.

Devido à natureza do crime, praticado com violência, além das circunstâncias judiciais negativas do artigo 59, do CP, bem como considerando o quantum de pena aplicado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena. Não bastasse isso, tais benefícios não seriam suficientes para cumprimento das finalidades da pena.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade da ré DELFINA MARIA ARROYO DE OLIVEIRA MAIA, portadora do RG 1.490.776, filha de Ramiro de Oliveira Ferreira e Antônia Arroyo de Oliveira, nascida em 27/11/1957, em São José do Rio Preto/SP, o que faço com fundamento no Art. 107, IV, primeira figura, do Código Penal.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para: 1) CONDENAR o réu WYNITU KELFS MAIA, portador do RG 27.695.974-7, filho de Elvio Maia e Delfina Maria Arroyo de Oliveira Maia, nascido em 19/12/1975, em São José do Rio Preto/SP, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), ao cumprimento da pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; 2) ABSOLVER o réu WYNITU KELFS MAIA das sanções do artigo 1º, inciso II, § 2º da Lei 9.455/97, por pelo menos duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado WYNITU ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei nº 11.608/03, observados, no entanto, os benefícios da gratuidade judiciária.

O réu WYNITU poderá recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo nessa condição, não havendo, por ora, motivos para a decretação da prisão preventiva.

Intimem-se, pessoalmente, os réus.

ComuniqueM-se às vítimas (artigo 201, §2º, CPP). Deixo de fixar indenização mínima, diante da ausência pedido expresso e exercício do contraditório, conforme exige a jurisprudência do Colendo STJ (artigo 387, IV, CPP).

Transitada em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15 da Constituição; extraia-se guia de execução definitiva, observando-se o regime inicial para cumprimento da pena.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

José Bonifácio, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA